



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת-שלוחת עכו

מס' תיק: 8/367/2020, 8/608/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין
עינת מידן בלום

התובע והנתבע שכנגד:

חזן דרור

באמצעות ב"כ עו"ד סיגל מיכאל
שד' המגינים 53 ת.ד 33319 חיפה

נגד

הנתבע והתובע שכנגד 1:

1. קאשי נסים

התובע שכנגד 2:

2. קאשי רחמים

שניהם באמצעות ב"כ עו"ד מגן איל
רחוב הבנקים 3 חיפה

פסק דין

תביעה ותביעה שכנגד לסילוק יד מהרכוש המשותף תוך השבת המצב לקדמותו.

1. במרכז ההליכים בית משותף הנמצא ברחוב חנה סנש 15 בקרית מוצקין, וידוע כגוש 10428 חלקה 156. מדובר במבנה דו-קומתי, הכולל 12 דירות, בכל קומה 6 דירות (להלן – **הבית המשותף**); המעבר בין הקומות נעשה דרך גרם מדרגות שנמצא במרכז הבית המשותף, המוביל למעין מרפסת צרה המשותפת לכל הדירות שבקומה העליונה (להלן – **מרפסת הגישה**).

2. התובע בתיק העיקרי מר דרור חזן (להלן – **התובע או חזן**) הוא בעל הזכויות בתת-חלקה 3; הנתבע והנתבע שכנגד מס' 1, מר נסים קאשי (להלן – **הנתבע או קאשי**) הוא הבעלים של תתי-חלקות 2, 7 ו-8. התובע שכנגד מס' 2, מר רחמים קאשי הוא בנו של הנתבע ובבעלותו תת-חלקה 9 (להלן – **רחמים**). התובעים שכנגד ייקראו להלן – **התובעים שכנגד**.

3. דירתו של חזן נמצאת בקומת הקרקע, מצפון ובצמוד לדירתו של קאשי (ת"ח 2); והשתיים חולקות חצר משותפת, בצדן המזרחי (להלן – **החצר הקדמית**). לקאשי שתי דירות נוספות הסמוכות זו לזו, בחלקה הדרומי של הקומה העליונה, אליהן צמודה דירתו של רחמים – שלושת אלו אינן מענייניו של ההליך.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת-שלוחת עכו**

מס' תיק: 8/367/2020, 8/608/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

4. בשנת 2007 הועברה לתובע מסבתו, ללא תמורה, זכות הבעלות בדירתו. אין חולק שבעת העברת הדירה לחזן, כללה הדירה תוספת חדר שנבנתה ללא היתר בנייה (להלן – **תוספת בנייה**). את דירותיו בבית המשותף, רכש קאשי החל משנת 2015.
5. בתביעה העיקרית עתר חזן לסילוק ידו של קאשי משטח החצר הקדמית, אותה סיפח לדירתו באמצעות התקנת שער וגדרות.
6. בתביעה שכנגד ביקשו התובעים שכנגד צו עשה להריסת תוספת הבנייה בדירת חזן, לסילוק הגדר שהוקמה על-ידו בחצר האחורית ולשינוי כיוון הכניסה לדירתו, דרך החצר הקדמית, כבעבר.
7. ביום 19.4.21 ביקרתי בבית המשותף בנוכחות הצדדים ובאי כוחם.
8. ביום 27.6.21 התקיימה ישיבת הוכחות בה העידו מטעם חזן מר פרנקל ראובן ומר גיא שפר וחזן עצמו. מטעם התובעים שכנגד העיד מר משה מצליח והתובעים שכנגד עצמם. הצדדים סיכמו טענותיהם בכתב וכעת נותר להכריע בכל אחת מן התביעות.

התביעה העיקרית (בתיק 8-367-2020)

טענותיו של חזן

9. בכתב תביעתו טען חזן להשתלטות של קאשי על הרכוש המשותף, שבאה לידי ביטוי בסיפוח החצר הקדמית לדירתו, על-ידי הקמת גדר נמוכה עשויה בלוקים/בטון ושער. בשטח החצר הציב קאשי חפצים אישיים בהם בריכת שחייה, ריהוט, מכונת כביסה ועוד. נטען שבמעשים אלו, עשה קאשי שימוש ייחודי ברכוש המשותף, תוך מניעת שימוש בחצר מחזן, לרבות גישה אל בלוני הגז ומוני המים והחשמל של דירתו.
10. עוד טען חזן, לנזק שגרם קאשי לרכוש המשותף, על-ידי שבירת המעקה המפריד בין מרפסת הגישה לבין תוספת הבנייה, בחלק הסמוך לגרם המדרגות, לצורך הנחת דשא סינטטי וציוד אישי על גג תוספת הבנייה; בכך פגע באיטום גג תוספת הבנייה וגרם לנזקי רטיבות בדירת חזן; מעבר לכך, יצר השימוש בגג תוספת הבנייה סכנה ממשית לנפילה.
11. לפיכך, ביקש התובע לחייב את קאשי להרוס את הגדר ואת השער שהקים בחצר הקדמית ולפנותה מחפציו האישיים. כן עתר התובע להורות לקאשי לתקן את הנזק שגרם למעקה. נוסף על האמור, ביקש חזן ליתן צו האוסר על קאשי לבצע כל פעולה או שינוי או שימוש ייחודי ברכוש המשותף,



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת-שלוחת עכו**

מס' תיק: 8/367/2020, 8/608/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

מבלי שקיבל את הסכמת יתר בעלי הדירות, ולאסור עליו להימנע מלהטריד או מלהפריע את מנוחתם של המחזיקים בדירתו, לרבות בדרך של השמעת מוזיקה קולנית בחצר הקדמית או עישון והשמעת רעש בסמוך לחלונות דירתו.

טענותיו של קאשי

10. בכתב הגנתו טען קאשי לחוסר ניקיון כפיים של חזן בהגשת תביעתו אשר בא לידי ביטוי בבניית חדר נוסף ללא היתר, בשינוי מיקום הכניסה לדירתו, ובסיפוח חלק מהחצר.

11. בהתייחס לכתב התביעה נגדו, טען קאשי שאין בפעולות שביצע בחצר הקדמית משום סיפוח ומניעת שימוש של התובע בחצר. אשר לטענות בדבר שבירת המעקה, הסביר קאשי שתוספת הבנייה בדירת חזן חסמה את המדרגות המובילות לדירותיו שבקומה העליונה; בלית ברירה, נאלץ "להסיר" חלק ממעקה מרפסת הגישה. אשר לטענה בדבר סיכון, טען הנתבע שתוספת הבנייה בדירת חזן שנבנתה ללא היתר, היא היוצרת סיכון ויש להורות על הריסתה.

דיון והכרעה - התביעה העיקרית

12. אין חולק שלדירת קאשי לא הוצמדו חלקים ברכוש המשותף, ומשכך כל השינויים שנטען כי בוצעו על ידו, נעשו בשטח הרכוש המשותף. יש לבחון מה טיב השימוש שנעשה ברכוש המשותף, האם נדרשות הסכמות בעלי הדירות האחרים, ואם כן, האם ניתנו הסכמות אלו.

13. כפי שפורט לעיל בהרחבה, התובע עתר לסעדים שונים שמטרתם להפסיק את השימוש הייחודי שעשה קאשי בחצר הקדמית, תוך השבת מצבה לקדמותו.

14. הנתבע בחר לייחד את כתב הגנתו לטענות בדבר פגמים בהתנהלותו של חזן, ולפעולות שביצע שלא כדין ברכוש המשותף; בשולי הדברים, התייחס קאשי בכלליות לטענות המופנות כלפיו בכתב התביעה, בציינו שאין בפעולות שביצע בחצר הקדמית משום סיפוח החצר הקדמית לדירתו לצורך שימוש ייחודי. אין למצוא בכתב הגנתו של קאשי הכחשה של הפעולות והשימושים המתוארים בסעיפים 3-4 לכתב התביעה, ולמעשה די באמור כדי לקבוע שטענות התובע לא נסתרו ודין תביעתו להתקבל.

15. ייאמר בעניין זה, שבמהלך ניהול ההליך פונתה החצר הקדמית על-ידי קאשי, הוסרו ממנה יריעות הבד והיא הונמכה על דרך הסרת גדר העץ החיצונית, כפי שעולה מן התמונות שהוגשו ע"י הנתבע ביום 30.5.21 (כן ראו: דברי הנתבע בפרוטוקול מיום 27.6.21, עמ' 15 שו' 1-5). יצוין שבהחלטת מיום 30.5.21 התבקשה תגובת התובע חזן לתמונות, אך זו לא הוגשה; גם בסיכומיו של חזן, אין



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת-שלוחת עכו**

מס' תיק: 8/367/2020, 8/608/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

למצוא התייחסות לתמונות אלו ולפעולות שבוצעו על ידי קאשי במהלך ניהול ההליך, למעט הנזק למעקה ולאיתוס תוספת הגג, אליהן אתייחס להלן. בסיכומים אף לא צומצמה רשימת הסעדים של התובע בסיכומיו, כמתבקש.

16. אשר לטענה בדבר גרימת נזק למעקה המרפסת בקומה העליונה (סעיף 5 לכתב התביעה) – משתוקן המעקה ע"י הנתבע, במהלך ניהול ההליך, יש להורות על מחיקת סעד זה. בעניין הנזק הנטען לאיתוס גג התוספת, לא ברורה טענת חזן בסיכומיו שהנזק לאיתוס לא תוקן, לאור הודעתו בדיון מיום 9.5.21: **"בתקווה שלא תהיה עוד חדירת מים, הנושא הזה טופל...ככל שהתיקון לא צלח אנחנו נחזור לכאן עוד מספר חודשים בשנית"** (פרוטוקול עמ' 1, שו' 9-11).

17. בנסיבות העניין, לאחר עיון בסיכומיו של התובע ובחינת הפעולות שביצע קאשי לשם השבת המצב לקדמותו – לגביהן לא נשמעה טענה או השגה מצד התובע – נותר ליתן סעד בעניין סילוקם של גדר העץ ושער הכניסה לחצר הקדמית (להלן, בפרק האחרון לפסק הדין).

התביעה שכנגד (בתיק 8-608-20)

טענות התובעים שכנגד:

18. לדברי התובעים שכנגד, על שטח החצר הקדמית בנה חזן חדר נוסף לדירתו, ללא היתר בנייה וללא הסכמת יתר בעלי הדירות. בקירות החדר פער שני חלונות, אחד משקיף דרומה - לכיוון הכניסה לדירת קאשי, והשני מזרחה - לכיוון החצר הקדמית.

19. תוספת הבנייה צמצמה את שטח המדרגות המובילות לקומה העליונה של המבנה, בניגוד לתנאי התקן. לדברי התובעים שכנגד, 8 מתוך 12 בעלי הדירות מתנגדים לבנייה זו שביצע חזן.

20. עוד טענו התובעים שכנגד, שחזן שינה את מיקום דלת הכניסה לדירתו, כך שכיום הכניסה לדירתו נעשית מצדו האחורי של הבית המשותף, ולא דרך החצר הקדמית, כפי שנבנתה במקור. את החצר האחורית הסמוכה לדירתו, סיפח חזן לדירתו באמצעות הקמת גדר, ובכך נמנע מרחמים, שדירתו שוכנת מעל דירתו של חזן, לבנות תוספת ממ"ד.

21. באין הסכמות מצד בעלי הדירות, בהעדר היתר בנייה, בשל חסימת האור לדירתו של קאשי (ת"ח 2) ופגיעה בפרטיותו, ביקשו התובעים שכנגד צו להריסת תוספת הבנייה והגדר שהקים חזן בחצר האחורית, וכן צו המחייבו באיתוס פתח דלת הכניסה לדירתו מכיוון החצר האחורית.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת-שלוחת עכו**

מס' תיק: 8/367/2020, 8/608/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

טענות חזן:

22. בכתב ההגנה שכנגד טען חזן שתוספת הבנייה נבנתה לפני שנים רבות על ידי הבעלים הקודמים של הדירה, ולאורך השנים הרבות שחלפו, לא נשמעה כל טענה מצד קאשי ובעלי הדירות האחרים.

23. עוד טען חזן, שבהתאם לאמור בסעיפים 71ב(א) ו-71ב(ג) לחוק המקרקעין, לצורך הרחבת דירה נדרש רוב של 75% מבעלי הדירות בבית המשותף שבידיהם 66% מהרכוש המשותף; לצורך העניין יש לראות במי שדירתו הורחבה בעבר, כמי שמסכים להרחבה דומה ביתר הדירות, ולצורך ההרחבה המבוקשת אין כל חשיבות לשאלה האם ניתן היתר בנייה. היות שבמהלך השנים הרחיבו 8 מבעלי הדירות את דירותיהן, הרי שיחד איתו, מדובר בהסכמת 9 מתוך 12 דירות, כלומר: ישנו רוב של 75% מבעלי הדירות בבית המשותף, בהתאם לנדרש בחוק המקרקעין, וזאת חרף התנגדות התובעים שכנגד.

24. ביחס ליתר הטענות, טען חזן שיש לדחות את הטענה להסתר האור על-ידי תוספת הבנייה, בהעדר חוות דעת מקצועית; כן נדחתה טענת קאשי לפגיעה בפרטיותו, הואיל לא קיים חלון בקיר שבין שתי הדירות. לגבי הטענה לשינוי פתחי החלונות והדלת, נטען ע"י חזן שגם אלו נעשו לפני שנים רבות, על-ידי הבעלים הקודמים של הדירה; ויש לראות בשתיקתם של אלו הסכמה.

25. ביחס לטענה לסיפוח חלק מהחצר האחורית לדירת חזן, נטען שאכן מזה שנים ישנו סיפוח של החצר האחורית לדירתו, בדומה ליתר הדירות בבניין, אך מדובר בסיפוח החצר בחלק שמול דירת חזן בלבד ובגבולותיה, זאת בשונה מקאשי, שסיפח לדירתו את כל החצר הקדמית – זו שמול דירתו וזו שמול דירת חזן. בסיכומיו טען התובע שנושא הסיפוח ירד מהפרק, הואיל והוגשה על ידי חזן בקשת היתר לבניית ממ"ד בחלק האחורי של הבית, וממילא הכניסה תחזור להיות מהחצר הקדמית.

דיון והכרעה - התביעה שכנגד

26. אין חולק שלדירת חזן לא הוצמדו חלקים ברכוש המשותף, ומשכך תוספת הבנייה בדירתו, נבנתה על שטח הרכוש המשותף. לפיכך, עותרים התובעים שכנגד להריסת תוספת הבנייה שבנה חזן בחצר הקדמית, לסילוק הגדר שהציב בשטח החצר האחורית, ולשינוי כיוון הכניסה לדירתו, כפי שהיה בעבר - דרך החצר הקדמית.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת-שלוחת עכו

מס' תיק: 8/367/2020, 8/608/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

27. לטענת חזן, יש לדחות את התביעה נגדו מטעמי שיהוי, התיישנות והסכמת בעלי הדירות הקודמים (בין אם מפורשות ובין אם בשתיקה). לחלופין, נטען שיש לדחות את התביעה, לאור קיומן של הסכמות קונסטרוקטיביות ברוב הנדרש על-פי סעיפים 71ב(א) ו-71ב(ג) לחוק המקרקעין.

28. קודם לבידור המחלוקת, ייאמר שלא הוכחו לפני טענותיו של חזן בדבר שיהוי או התיישנות המצדיקות את דחיית התביעה. ככלל, לצורך הוכחת שיהוי, אין די בחלוף הזמן; ועל הטוען לשיהוי להוכיח גם ששינה מצבו לרעה [ראו: ע"א 6805/99 תלמוד תורה הכללי והישיבה הגדולה עץ חיים בירושלים נ' הועדה המקומית לתכנון ובנייה ירושלים, פ"ד נז(5) 433 (2003); ע"א 4352/15 קורן נ' הראל (נבו, 2.8.2017)].

29. טענתו של חזן לשיהוי הועלתה באופן כללי. לא נטען על ידי חזן ששינה מצבו לרעה, ולא בכדי, שכן הדירה הועברה לבעלותו כשתוספת הבנייה כבר קיימת בה.

30. גם הטענה להתיישנות התביעה נדחת. הלכה היא שהעוולה של הסגת גבול, יוצרת עילת תביעה חדשה בכל יום שבו היא נמשכת, ועל-כן אינה כפופה לכללי ההתיישנות (ראו: ע"א 35/71 חברת ישראל אוסטרליה להשקעות פרדסנות ומטעים בע"מ נ' מושב בני דרור אגודה חקלאית שיתופית בע"מ, פ"ד כז(1) 225 (1972); ע"א 367/83 מ' שושן חברה לבניין ופיתוח בע"מ נ' רמות גזית בע"מ, פ"ד לט(1) 633; ע"א 590/67 קלינמן נ' ד"ר מירון חרושת כימית בע"מ, פ"ד כב(2) 929).

31. לגופם של דברים - אין מחלוקת בין הצדדים שתוספת הבנייה בדירת התובע, נבנתה על-ידי בעלי הזכויות הקודמים בדירה, ולא על ידו. מעדויות חזן והעדים, שלא נסתרו, עולה שתוספת הבנייה עומדת על תלה משנות ה-90 וכך גם הכניסה לדירתו מהחצר האחורית. קרי, מדובר בתוספת שנבנתה כ-17 שנה לפני שהועברו הזכויות בדירה לידי חזן, וכ-30 שנה לפני רכישת קאשי את דירותיו.

32. אין לפני טענה שתוספת הבנייה נבנתה בהסכמה מפורשת של בעלי הדירות בבית המשותף. כל שנטען בהקשר זה על-ידי התובע הוא שעד להגשת התביעה שכנגד, לא נשמעה טענה נגד תוספת הבנייה מצד התובעים שכנגד ואף לא מצד בעלי הדירות האחרים. בעניין זה עולה מעדותו של קאשי (פרוטוקול דיון מיום 27.6.21 עמ' 15 שו' 15-17), שלאחר רכישת דירתו (ת"ח 2) התלונן בפני חזן שהחלון בתוספת הבנייה משקיף אל דירתו ופוגע בפרטיותו; בעקבות זאת, אטם חזן את חלון הדירה, ופתח אחר במקומו. לראשונה בעדותו טען קאשי שביקש מחזן להרוס את תוספת הבנייה, אך הוא סירב, ומאז לא פעל בעניין. נמצא אם כן, שהתובעים שכנגד דרשו את סילוק תוספת הבנייה לראשונה בתביעה שלפניי.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת-שלוחת עכו

מס' תיק: 8/367/2020, 8/608/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

33. מכאן יש לבחון, האם יש בשתיקתם של התובעים שכנגד במשך כ-5 שנים ולשתיקתם של בעלי הזכויות האחרים בבית המשותף לאורך עשרות השנים שחלפו, להקנות לתובע זכות קניינית. ככל שהתשובה שלילית, יש להכריע בשאלה, האם קיימת לתובע זכות אחרת להמשיך להחזיק בחלק שבו הוא עושה שימוש ייחודי ברכוש המשותף.

34. סעיף 16 לחוק המקרקעין קובע ש"בעל מקרקעין ומי שזכאי להחזיק בהם זכאי לדרוש מסירת המקרקעין ממי שמחזיק בהם שלא כדין". די שיוכיח בעל המקרקעין בעלותו בהם, ומכאן עובר הנטל למי שטוען לזכות להמשיך להחזיק בקרקע, הגוברת על זכותו הקניינית של הבעלים [ע"א 127/77 קפה נ' לוי, פ"ד לא(3) 455, 465 (1977); ע"א 483/62 קוך נ' לנדוי, פ"ד יז 1953 (1963)].

35. הכלל הוא, שלצורך הוצאת חלקים מהרכוש המשותף והצמדתם לדירה אחרת יש צורך בהסכמה של כל בעלי הדירות (סעיפים 55(ג) ו-62(א) סיפא לחוק המקרקעין). משמעותה של "הצמדה" כמובנה בחוק, היא גריעת חלק מסוים מהרכוש המשותף ושיוכו של אותו חלק לדירה פלונית; בכך חדל אותו חלק להיות רכוש משותף, והופך להיות נכס פרטי של בעלי הדירה שאליה הוצמד. "ההצמדה" הינה הוצאת חלק מסוים מהרכוש המשותף ושיוכו (הצמדתו – בלשון החוק) לדירה פלונית. ההצמדה חייבת להיות קשורה לדירה ואין היא יכולה לעמוד בפני עצמה. משבוצעה ההצמדה, חדל החלק שהוצמד להיכלל ברכוש המשותף ודינו לכל דבר כדין הדירה אליה הוצמד" [ראו: אריה איזנשטיין, יסודות והלכות בדיני מקרקעין - חלק שלישי בתים משותפים, 113 (2001)].

36. הואיל ומדובר בפעולה המעניקה זכות קניינית לדירה מסוימת, תוך כדי פגיעה בזכותם הקניינית של יתר בעלי הדירות ברכוש המשותף, הבאה לידי ביטוי בצמצום חלקו של כל דייר ברכוש המשותף (סעיף 55(א) לחוק המקרקעין), נדרשת הסכמה פוזיטיבית, ברורה ומפורשת של כל בעלי הדירות [ע"א 5043/96 גלמן נ' הררי-רפול, פ"ד נ"ד(3) 389, 394 (2000)]. הפסיקה הכירה בהסכמות שניתנו בדיעבד כהגנה מפני תביעה לסילוק יד, ואף תוך כדי ההליך המשפטי [ראו: עש"א (מחוזי-חיפה) 31624-03-14 רום נ' רוזנצווייג (נבו, 11.12.2014)], ואולם אין די בשתיקה, בהעדר התנגדות או בהסכמה משתמעת כדי להכשיר קניינית פעולות העולות כדי הצמדה, כמובנה בחוק.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת-שלוחת עכו

מס' תיק: 8/367/2020, 8/608/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

37. מכאן, שאין די בחלוף השנים וגם אם מדובר בעשרות שנים, כדי להקנות לתובע זכות קניינית בתוספת הבנייה שנבנתה על הרכוש המשותף, בלי שקיבל את הסכמתם המפורשת של כל בעלי הדירות.

האם קיימות הסכמות קונסטרוקטיביות לתוספת הבנייה?

38. בהעדר הסכמות מפורשות של כל בעלי הדירות לתוספת הבנייה שבדירתו, טען חזן שיש לראות בבעלי דירות שהרחיבו את דירותיהם "הרחבה דומה" לתוספת הבנייה שבדירתו - כמי שמסכימים לה, מכוח סעיף 71 לחוק המקרקעין הקובע:

"(א) על אף הוראות סעיף 62(א) סיפה, או סעיף 12(ב) לתקנון המצוי שבתוספת, רשאים מי שבבעלותם שלושה רבעים מהדירות ושני שלישים מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם, להחליט בדבר הוצאה של חלקים מסויימים מהרכוש המשותף והצמדתם לדירה פלונית, לשם בניה שמטרתה הרחבת אותה דירה, וכן להחליט בדבר חלוקת זכויות הבניה הנדרשות לצורך זה, ואולם, היה נושא ההחלטה כאמור הרחבת דירה פלונית אחת או יותר לשם בניית מרחב מוגן דירתי או מרחב מוגן קומתי, רשאים להחליט על כך מי שבבעלותם שישים אחוזים מהדירות.

(ב) לא תתקבל החלטה כאמור בסעיף קטן (א) אם יש בה כדי לפגוע בזכויות בניה יחסיות של כל בעל דירה להרחבה לפי סימן זה.

(ג) בעל דירה שהורחבה יראה כמי שהסכים להרחבה דומה של כל דירה אחרת באותו בנין."

39. כחריג לכלל הקובע שנדרשת הסכמה מפורשת של כל בעלי הדירות לצורך הצמדת חלק מסוים מהרכוש המשותף לדירה פלונית, קובע סעיף 71 לחוק המקרקעין שבהצמדת חלק מסוים לדירה פלונית **לצורך הרחבת דירה**, די בהסכמות של 75% מבעלי הדירות שלדירותיהם צמודים 2/3 מהרכוש המשותף, אך תנאי זה כשלעצמו, אינו מספיק. סעיף 71 ב לחוק המקרקעין קובע, שכדי ליהנות מרוב מופחת יש להוכיח התקיימותם של שני תנאים נוספים:

א. קיומה של **סמיכות פיזית** בין הדירה לבין תוספת ההרחבה (ראו: רע"א 1462/10 עטייה נ' **שגיא** (נבו, 2.8.2012) – אין חולק שתוספת הבנייה בדירת התובע סמוכה לדירתו והיא המשך ישיר שלה. לא נטען אחרת ע"י הנתבע וכך התרשמתי אף מביקורי במקום ביום 19.4.21.

ב. קיומו של **אישור תכנוני** המעיד שמדובר ב"הרחבה", כהגדרתה בסעיף 71 לחוק המקרקעין: "הגדלה של שטח דירה קיימת בבית משותף שניתן לקבל לגביה היתר בניה לפי תכנית בת-תוקף" - תנאי זה לא הוכח על-ידי התובע. צודק התובע בטענתו, שבעל דירה המבקש להרחיב את דירתו, אינו נדרש להוכיח קיומו של היתר להרחבה המבוקשת על-ידו. לצד האמור, חלה



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת-שלוחת עכו**

מס' תיק: 8/367/2020, 8/608/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

על בעל הדירה חובה להוכיח שניתן לקבל היתר לעבודות הבנייה המבוקשות "לפי תכנית בת-תוקף". בדיון מיום 9.5.21 התייחס ב"כ התובע לתכנית בנייה שבכוונת התובע להגיש במסגרת בקשה להיתר בנייה, הכוללת בין היתר את הכשרת תוספת הבנייה (פרוטוקול מיום 9.5.21, עמ' 2 שו' 15-16). ואולם לא מונחת לפניי החלטה תכנונית המאשרת את תוספת הבנייה, או למצער, אישור בתנאים. אף לא צורפה חוות דעת תכנונית, שיכולה הייתה ללמד על סבירות גבוהה למתן היתר בנייה, ולמעשה, אין לפניי ראיה שבכלל הוגשה בקשה רלבנטית לרשויות התכנון.

40. בנסיבות אלו, שבהן לא מתקיים התנאי בדבר קיומו של אישור תכנוני, מתייגר הצורך לדון בשאלה האם יש לתובע הסכמות ברוב הנדרש (75% מבעלי הדירות שלדירותיהם צמודים 2/3 מהרכוש המשותף), למרות זאת, ראיתי להתייחס לדברים.

41. כאמור, התובע לא טען שניתנה לו הסכמתם של בעלי הדירות אלא טען להסכמות קונסטרוקטיביות של בעלי הדירות שהרחיבו דירותיהם הרחבה דומה לתוספת הבנייה בדירתו.

42. התובע מסתמך על תשריט שהגיש קאשי, כחלק מבקשתו להיתר בניית הממ"דים בדירותיו, ממנו מבקש התובע ללמוד על הרחבות הבנייה שביצעו בדירותיהם חלק מבעלי הדירות. לפי פירוט שהובא על ידי חזן, נבנו על-ידי בעלי הדירות האחרים, השטחים הבאים: **ת"ח 1** – תוספת ממ"ד בשטח 12 מ"ר; **ת"ח 2** (קאשי) – תוספת ממ"ד בשטח 12 מ"ר; **ת"ח 4** – תוספת חדר בשטח 10 מ"ר; **ת"ח 5** – תוספת חדר בשטח 10 מ"ר; **ת"ח 6** – הורחבה בשטח 70 מ"ר בכל החזיתות; **ת"ח 7** (קאשי) – תוספת ממ"ד בשטח 12 מ"ר; **ת"ח 8** (קאשי) – תוספת ממ"ד בשטח 12 מ"ר; **ות"ח 12** – תוספת 70 מ"ר בכל החזיתות.

43. לטענת חזן, מניין הסכמותיהן הקונסטרוקטיביות של 8 בעלי הדירות, יחד עם הקול שלו, מקים את הרוב הנדרש לצורך הכשרת תוספת הבנייה בדירתו. התובעים שכנגד לא סתרו את הנתונים עליהם הסתמך התובע, אלא טענו באופן כללי, שבניית ממ"ד אינה דומה להרחבה של חדר, טענה זו יש לדחות לנוכח הפרשנות שניתנה בפסיקה, על-פיה, לא נדרשת זהות מלאה בין ההרחבה שבוצעה בעבר לבין הבנייה אותה מבוקש להתיר. בהקשר זה אפנה לדברים הבאים בעש"א (מחוזי-חיפה) 22123-10-10 **חדד נ' זינגר** (נבו, 14.3.2011):

"אחד הקריטריונים שנבחן, בנסיבות בהן מבקש בעל דירה לבצע הרחבה דומה בדירתו, מבוסס על השטח הנוסף שבו מבקש בעל הדירה להרחיב



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת-שלוחת עכו**

מס' תיק: 8/367/2020, 8/608/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

דירתו. נדרשת פרופורציה מסוימת, ואם כי לא זהות, בין שטח ההרחבה המבוקש והרחבות קודמות שביצע בעל דירה אחרת בבניין. כך, לא מתקבל על הדעת שמקום שדייר הרחיב דירתו במספר מטרים ספורים, תאושר הרחבה המשתרעת על עשרות מטרים כ"הרחבה דומה".

עם זאת, משנקט המחוקק במונח "הרחבה דומה", ברור הדבר מאליו כי אין לפרש את המונח "הרחבה דומה" על בסיס קריטריון בלעדי זה של שטח שנוסף לדירה, שכן אילו לכך התכוון המחוקק, היה קובע במפורש כי יראו את בעל הדירה שהרחיב דירתו כמסכים להרחבה בשטח ו/או בשיעור דומה, וכאמור, הגדרה זו לא נקבעה בתיקון מס' 18 לחוק המקרקעין. לפיכך, הגם שלא ניתן להתעלם מקריטריון השטח שנוסף, אין זה יכול לשמש כקריטריון בלעדי" (ראו

גם: ע"א (מחוזי-ירושלים) 3235/02 דוד נ' גדולטר בכבוד (נבו, 2.3.2003)

44. בסיכום הדברים, אני קובעת שלא ניתן להחיל את סעיף 71ב לחוק המקרקעין על תוספת הבנייה שבדירת התובע ומשכך, אין התובע יכול ליהנות מההקלה שבחוק, הקובעת רוב מופחת בבנייה לצורך הרחבת דירה. משמעות הדברים היא שהכשרת תוספת הבנייה בדירת חזן, טעונה הסכמתם של כל בעלי הדירות.

משמעות שתיקתם של בעלי הדירות בנוגע לתוספת הבנייה

45. בהעדר הסכמה מפורשת של בעלי הדירות לתוספת הבנייה, ומשלא התקבלה טענת התובע שניתן להכשיר את תוספת הבנייה בדירתו על-ידי הסכמותיהם הקונסטרוקטיביות של בעלי דירות שהרחיבו דירותיהם, יש לדון בטענתו החלופית, שעניינה זכות שימוש בשטח המשותף מכוח שתיקת בעלי הדירות במשך שנים רבות. בעניין זה טען חזן בסיכומיו (סעיפים 5 ו-8) שבעלי הדירות מנועים מלהתנגד לתוספת הבנייה, וזאת לנוכח שתיקתם לאורך השנים. הגם שהדברים לא נאמרו במפורש, נראה שכוונת התובע ל"רישיון במקרקעין" להחזיק בשטח המשותף. הדיון בפרק זה יתייחס אף לטענה בדבר סיפוח חלק מהחצר האחורית על-ידי חזן.

46. סיכום ממצא בדבר הזכות להחזיק בקרקע מכוח רשות מכללא הובא בע"א 483/16 יהודאי נ' חלמיש – חברה משלתית – עירונית לדיור שיקום ולהתחדשות שכונות בתל אביב בע"מ (נבו, 3.10.2017):

"המונח "רישיון במקרקעין" מתייחס להענקת זכות להחזקה ושימוש במקרקעין בתמורה או ללא תמורה, במפורש או מכללא.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת-שלוחת עכו

מס' תיק: 8/367/2020, 8/608/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הרישיון אינו חלק מהזכויות המנויות ב**חוק המקרקעין**, התשכ"ט-1969, אולם פסיקתו של בית משפט זה הכירה בו כמוסד המבוסס על שיקולים של צדק ומתאים למקרים מסוימים שבהם לא רכש המחזיק זכות קניינית במקרקעין לכל דבר ועניין. ככלל, רישיון במקרקעין הוא הדיר וניתן לביטול, אך ישנם מקרים שבהם הצדק דורש למנוע מנותן הרישיון לבטלו. במקרים שבהם בעל הזכויות במקרקעין הציג בפני אדם מצג בנוגע לשימוש במקרקעין – אף ללא הסכם מפורש – יש מצבים שבהם ניתן להכיר בקיומו של רישיון "מכוח השתק" לשם עשיית צדק בין הצדדים. לצורך כך, נבחנו בפסיקה, בין השאר, כוונת הצדדים, הציפייה שיצר בעל המקרקעין אצל בעל הרישיון, מידת הסתמכותו של האחרון על הרישיון והנזק שנגרם לו עקב כך, משך השימוש במקרקעין, ועוד. כמו כן, נקבע כי לבתי המשפט נתון שיקול דעת רחב אף בקביעת הסעדים מכוחו של הרישיון – החל ממתן פיצוי כספי בגין ביטול הרישיון וכלה בקביעה כי הרשות בלתי הדירה ואינה ניתנת לביטול – והכל על-פי נסיבות המקרה הקונקרטי (ראו: [ע"א 346/62 רכטר נ' מנהל מס עזבון, ירושלים, פ"ד יז 701, 710 \(1963\); ע"א 515/76 לוי נ' ויימן, פ"ד לא \(2\) 127 \(1977\); ע"א 32/77 טבוליצקי נ' בית-כנסת ובית-מדרש החסידים, פ"ד לא \(3\) 210, 214 \(1977\); רע"א 2701/95 כנעאן נ' גזאוי, פ"ד נג \(3\) 151, 170 \(1999\); ע"א 7139/99 אלוני נ' ארד, פ"ד נח \(4\) 27, 42 \(2004\); ע"א 633/08 מינהל מקרקעי ישראל נ' חיטמן, \[פורסם בנבו\] פסקאות כ"ג-כ"ד \(9.1.2014\); עניין אלקיעאן, בפסקה 6 לחוות דעתי; \[ע"א 6757/13 אביטס נחום נ' מדינת ישראל – רשות הפיתוח, \\[פורסם בנבו\\] פסקה 22 \\(19.8.2015\\) \\(להלן: עניין נחום\\); בע"מ 1894/16 פלוני נ' פלונית, \\[פורסם בנבו\\] פסקה 11 \\(10.5.2017\\); מיגל דויטש קניין כרד ב 416 \\(1999\\); נינה זלצמן "רישיון במקרקעין" הפרקליט מב 24, 30 \\(1995\\); \\[נינה זלצמן "רשות חינוך במקרקעין כ'השאלת מקרקעין" עיוני משפט לה 265, 270-271 \\\(2012\\\); יהושע ויסמן דיני קניין: החזקה ושימוש - 488-487 \\\(2005\\\)...\\]\\(#\\)\]\(#\)](#)



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת-שלוחת עכו**

מס' תיק: 8/367/2020, 8/608/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

47. אם כן, בשונה מהקניית זכויות במקרקעין, לשם יצירת רישיון במקרקעין אין צורך בהסכמה פוזיטיבית ומספיקה הסכמה מכללא, עליה ניתן ללמוד מהתנהגות הצדדים. העובדה שעבר זמן רב מאז תפיסת הקרקע ע"י פלוני, ובמשך כל אותו זמן נמנע בעל הקרקע מתגובה כלשהי, למרות שידע על התפיסה, יכולה להעיד על הסכמתו, וליצור רישיון מכללא. למעניק הרישיון זכות לביטול הרשות בכל עת, זאת על-ידי גילוי דעתו כלפי פלוני, שאין ברצונו להרשות עוד את הפעולות שלגביהן ניתנה הרשות. "זו היא רשות חינוך המתחדשת מרגע לרגע, כל עוד לא פעל בעל המקרקעין לסילוקו של פלוני. אולם, ככל שהיא נמשכת בלא תגובה מצידו של בעל המקרקעין היא יוצרת ציפיה אצל פלוני להמשיך קיומה גם בעתיד, אשר בנסיבותיו של המקרה יהיה על בית המשפט להביא בחשבון, לענין קציבת המועד לפינוי" [נינה זלצמן רישיון במקרקעין הפרקליט מב 24, 57 (1995); כן ראו: ע"א 618/05 דיאמנשטיין נ' מחלקת עבודות ציבוריות – מדינת ישראל (נבו, 21.3.2007)]

48. כאמור, על-אף שהדברים לא נטענו באופן מפורש על-ידי חזן, גם אם אניח לטובתו, ששתיקת בעלי הדירות לתוספת הבנייה במשך עשרות שנים עולה כדי "רישיון במקרקעין", אין בנתון זה כשלעצמו להגן עליו מפני תוצאה אפשרית של פינוי. רישיון במקרקעין הניתן לביטול הוא לעולם אישי [ע"א 618/05 שאוזכר לעיל; ע"א 309/54 נאמן נ' ראש העיר, חברי המועצה ובני העיר תל-אביב-יפו, פ"ד י" 1953 (1956)]. ככל שלבעלי הזכויות הקודמים בדירה ניתן רישיון לעשות שימוש בשטח המשותף, הרי שרישיון זה פקע עם העברת הזכויות בדירה לחזן בשנת 2007. גם לו הייתי קובעת, שעומדת לחזן רשות מכללא הבאה לידי ביטוי בשתיקתם של בעלי הדירות ממועד רכישתו את הדירה, הרי שאין לראותה כרשות בלתי-הדירה. מעבר לטענתו בדבר חלוף השנים, לא טען חזן שביצע השקעות בתוספת הבנייה, אותה כאמור קיבל כ"מוצר מוגמר" עם הדירה; חזן אף לא טען שיש לו אינטרס לגיטימי אחר הראוי להגנה מלבד השנים שחלפו ללא מחאה או התנגדות הדיירים. העובדה שמדובר בבנייה שאינה חוקית, הנתונה באופן טבעי תחת "איום" הריסה, שוללת ציפייה לגיטימית של בר-הרשות לזכות במקרקעין, עליה ראוי להגן [ראו: ת"א (מחוזי-תל-אביב) קונצ'צקי נ' שפלן (נבו, 3.4.2006)].

49. לאור האמור, ככל שהייתה לתובע חזן רשות מכללא בשטח הרכוש המשותף, הרי שמדובר היה ברשות הדירה הניתנת לביטול. בהגשת התביעה נגדו על-ידי התובעים שכנגד, ניתן לראות כהודעת התובעים שכנגד על ביטול הרישיון, ועם ביטול הרישיון מחויב חזן לסלק ידו משטח הרכוש המשותף.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת-שלוחת עכו**

מס' תיק: 8/367/2020, 8/608/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

50. משקבעתי שממועד הגשת התביעה בוטל רישיונו של הנתבע ואינו בר-רשות בשטח המשותף, אפשר היה לחייבו בתשלום דמי שימוש ראויים, כטענת התובעים שכנגד; ואולם משלא נכלל סעד זה בכתב התביעה שכנגד (ואף לא הובאו ראיות בדבר שווי דמי שימוש), יש לדחות טענה זו.

51. לנוכח התוצאה אליה הגעתי, מתייתר הצורך לדון בטענת התובעים שכנגד להסתיר אור הנגרם להם על-ידי תופסת הבנייה, ומכול מקום מדובר בטענה שהועלתה באופן כללי ללא תמיכה ראייתית.

סיכום

52. התביעה בתיק 8/367/2020 - הואיל ולאחר הגשת התביעה ובעקבותיה, פעל קאשי להשבת מצב החצר הקדמית לקדמותו, נותר להורות ביתר הסעדים כדלקמן:

א. הנתבע קאשי יסלק את גדר העץ שחיבר למעקה האבן המקיפה את החצר הקדמית בתוך 30 יום.

ב. הנתבע קאשי יסלק את שער החצר הקדמית בתוך 30 יום.

ג. משפונתה החצר, נמחק הסעד שבסעיף 8ב לכתב התביעה.

ד. משתוקן המעקה, אני מורה על מחיקת הסעד שבסעיף 8ג' רישא לכתב התביעה.

ה. הסעד לתיקון ליקויי רטיבות בגג תוספת הבנייה התייתר לאור הודעת התובע בדיון מיום 9.5.21 על הפסקת הרטיבות בדירתו (פרוטוקול הדיון, עמ' 1 שו' 9) ואני מורה על מחיקתו.

ו. הסעדים המבוקשים בסעיפים 8ד'-8ה' לכתב התביעה התייתרו, ואני מורה על מחיקתם.

53. התביעה שכנגד בתיק 8/608/2020 – מהנימוקים שהובאו לעיל, התביעה שכנגד מתקבלת במלואה, ואני מורה לתובע חזן לסלק ידו משטח הרכוש המשותף, ובכלל זה להרוס את תוספת הבנייה,



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת-שלוחת עכו**

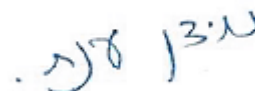
מס' תיק: 8/367/2020, 8/608/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

להסיר את הגדר שבצדו האחורי (מערבי) של הבית ולאטום את פתח הדירה הקיים שם. לאחר פעולות אלו, על התובע לבצע תיקונים להשבת מצב הבית לקדמותו, ובכלל זה תיקוני טיח וצבע ופינוי פסולת. הצו יבוצע בתוך 90 יום ממועד פסק הדין.

54. לנוכח התוצאה אליה הגעתי, שמשמעותה קבלת התביעה והתביעה שכנגד, אני מורה שכול צד יישא בהוצאותיו.

ניתן ביום ג' טבת תשפ"ב, 07 בדצמבר 2021, בהעדר הצדדים.


**עינת מירון בלום
מפקחת על רישום מקרקעין**